

1503086-73.2020.8.26.0269

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEYVID GONCALVES DE OLIVEIRA

Data da Audiência:

17/03/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1503086-73.2020.8.26.0269 - Controle 2020/001978

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEYVID GONCALVES DE OLIVEIRA

Data da Audiência:

17/03/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, e do Acusado Deyvid Gonçalves de Oliveira. Na "sala virtual" permaneceram exclusivamente o Defensor e seu representado para contato prévio. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. Foi ouvida a testemunha Fábio Brochieri Machado arrolada pelas partes. Em seguida o réu foi interrogado. Os depoimentos foram registrados pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM^(a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, acha-se processado o acusado como incurso no artigo 33 c.c. 40, inciso III, ambos da Lei de Tóxicos, em face dos fatos detalhadamente narrados na denúncia. Concluída a instrução, a ação penal merece proceder. A materialidade delitativa encontra respaldo no laudo de exame químico-toxicológico acostado aos autos. Autoria e existência delitativa, ao seu turno, vêm comprovadas nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório. Ouvido nos autos, tanto em juízo como em solo judicial, o agente de segurança penitenciária narrou sobre o encontro da droga

num pacote enviado ao acusado, então detento da penitenciária. As palavras do agente revestem-se de imensurável valor probatório, uma vez que isentas e desprovidas de qualquer intenção de prejudicar o agente. Demais disso, não há nenhum elemento capaz de indicar uma suposta suspeição do agente público; ao contrário, revela de forma absolutamente convincente toda dinâmica da diligência que resultou na apreensão do entorpecente na penitenciária. Dessa forma, patente a conduta atribuída ao réu, sendo certo que a quantidade da droga, em um pacote de bolachas, indicam claramente que se destinava, sim, a ulterior entrega ao consumo de outros detentos, tanto é que o próprio acusado, nas oportunidades em que ouvido a respeito, apresentou versões contraditórias, mas jamais foi capaz de refutar que a droga era a ele destinada. Ao contrário disso, tentou em seu interrogatório judicial justificar a conduta em razão de um problema com um celular que não lhe pertencia e foi apreendido na penitenciária, pelo que teria sido cobrado por integrantes de uma facção criminosa para que recebesse a droga em compensação do prejuízo. Daí é que foi coagido a receber a droga, mas não foi seu pai quem a enviou, mas sim outra pessoa que utilizou seus dados para a remessa. Essa versão resta isolada, não tendo como ser acolhida, além do que não é apta a isentá-lo da responsabilidade pelo delito, haja vista que o comprovado é que voluntariamente recebeu as drogas que se destinavam a entrega ao consumo de terceiros. Portanto, demonstradas autoria e materialidade, pugna a Justiça Pública pela procedência da ação penal, condenando-se o acusado nos termos da denúncia. Não se apresenta cabível a aplicação do redutor ao tráfico, haja vista a incidência da causa de aumento decorrente da prática do crime no interior do instituto prisional, devendo, outrossim, ser a pena base fixada acima do patamar mínimo, pois o acusado é reincidente específico, devendo, na mesma toada, ser fixado regime inicial fechado para o débito da sanção carcerária. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: MM. Juiz: O acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33 c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06. Ocorre que a pretensão acusatória não merece prosperar, visto que as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao acusado. I. DA NECESSÁRIA ABSOLVIÇÃO DO RÉU: a) Encomenda que não chegou ao seu destino. Ato preparatório. A denúncia descreve que o réu adquiriu, com a finalidade de venda e entrega a terceiros, 15 (quinze) invólucros de "maconha", com peso líquido total de 71,25g (setenta e um gramas e vinte e cinco centigramas) - fls. 70-72. No entanto, as circunstâncias narradas pela denúncia não foram minimamente comprovadas. Ainda que considere crível que o réu tenha "encomendado" a droga apreendida (fato também, que não ficou comprovado e será discutido no tópico seguinte), inexistente nos autos elemento de prova que ratifique a entrega de drogas a terceiros, por parte do réu. Dispõe o Código Civil que "a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos, antes da tradição" (art. 1.267). Assim, eventual encomenda, por parte do réu, para que seu genitor enviasse, pelo correio, o entorpecente até o presídio, não implica em aquisição da droga. Quando muito se poderia dizer que a encomenda se trataria de procedimento preparatório da aquisição, mas sem a tradição da droga ao suposto encomendante não está consumado o negócio jurídico. Por outro lado, o réu não chegou a receber a drogas (mas apenas a assinar o termo de responsabilidade com relação ao conteúdo - que, conforme se demonstrará, desconhecia), não se consumou a comercialização dentro do estabelecimento prisional, como noticiado na denúncia, já que o entorpecente foi apreendido antes da hipotética entrega pretendida. Além disso, nenhuma prova consta dos autos no sentido de que o réu vendesse drogas dentro da penitenciária. Os agentes penitenciários nada mencionaram sobre qualquer ato de comércio por parte do réu ou até mesmo avistado qualquer droga com ele. Nenhuma diligência policial nesse sentido foi realizada. Assim, como o fato descrito pelo Ministério Público na inicial acusatória (aquisição, entrega e venda) não restou minimamente comprovado, necessária a absolvição do réu das imputações constantes da denúncia, valendo os mesmos argumentos em relação ao delito de associação ao tráfico. b) Ausência de provas de que o réu tivesse ciência do conteúdo da encomenda. Como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz mister um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação

de um édito condenatório. Não é, todavia, o que ocorre na hipótese dos autos. Os agentes penitenciários ouvidos narraram, apenas, circunstâncias da apreensão do objeto, narrando que logo efetuaram a revista, antes da entrega ao réu. Não fizeram qualquer menção sobre terem visto o réu na posse de drogas ou de já terem visualizado o réu comercializando drogas no presídio. O réu negou que tivesse ciência de que havia entorpecentes no meio das bolachas, dizendo apenas que deu os dados de seu genitor para outros detentos que te ameaçaram, porque estava devendo um valor em dinheiro, pois havia perdido um celular pertencente a outro detento. Reiterou integralmente o depoimento prestado na própria penitenciária quando ouvido em declarações. Ou seja, não há absolutamente nada que indique a prática delitiva por parte do acusado: não há como afirmar que ele soubesse do conteúdo da encomenda. Não há como imputar o delito ao acusado tão somente pelo fato de alguém ter lhe mandado a encomenda contendo entorpecentes, sendo que não há provas de que ele tivesse ciência da existência droga. A acusação não se desincumbiu o ônus de comprovar os fatos que alega. Tais situações colocam em dúvida a versão apresentada. Diante disso, é o caso de absolvição do réu nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 3.

Desclassificação. Subsidiariamente, como a acusação se baseia, tão somente, em apreensão de diminuta quantidade de entorpecentes e como o réu não foi preso entregando ou vendendo algo para terceiros, mas apenas recebendo pequena quantidade de entorpecente, a conduta mencionada melhor se adequa àquela prevista no art. 28 da lei de drogas. A distinção do tipo legal do artigo 28 da Lei n. 11.343 do tipo penal do art. 33 da mesma lei se dá por força do elemento subjetivo específico “para consumo pessoal”. Conquanto o tipo do art. 28 contenha mais elementos subjetivos, não cabe à Defesa provar esse fim específico, mas sim cabe ao acusador demonstrar que esse fim não existia; e isto por força do princípio da presunção de inocência e da fórmula do in dubio pro reo, que determinam que se presume que o acusado incorreu no tipo penal menos grave enquanto o conjunto probatório não indicar seguramente no sentido contrário. Desta maneira, diante da ausência de evidências de que o réu visasse comercializar e obter lucro (circunstância inerente ao tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06) deve prevalecer o entendimento de que a classificação jurídica correta para a conduta atribuída a ele é a do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, devendo-se operar, portanto, a desclassificação, com suas consequências legais. II. TESES SUBSIDIÁRIAS. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer-se: a) a fixação da pena-base do acusado no patamar mínimo legal; b) seja fixado regime inicial semiaberto, mesmo que, frise-se, se trate do crime de tráfico, em conformidade com o entendimento já sumulado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmulas nº 718 e 719) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 440), bem como considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF – Pleno – HC nº 111.840/ES – rel. Min. Dias Toffoli), observando-se, ainda, o disposto no artigo 387, § 2º, do CPP; c) o afastamento da causa de aumento de pena pleiteada, visto que não basta que o delito aconteça no interior do presídio, sendo necessário comprovar que o acusado pretendia efetivar comércio de drogas voltado ao sistema penitenciário, o que não ocorreu no caso; d) a possibilidade

de o acusado apelar em liberdade, nos moldes do que estabelece o artigo 8, item 2, alínea “h”, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. DEYVID GONÇALVES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 40, inc. III, da Lei n. 11.343/2006, porque, em 15 de julho de 2020, por volta das 15 h e 45 min, nas proximidades da Penitenciária Jairo de Almeida Bueno, situada à Rodovia Gladys Bernardes Minhoto, km 63, no Bairro Capão Alto, nesta Cidade e Comarca, adquiriu, para fins de comércio, quinze porções de “maconha”, com peso de 71,25 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar. Notificado, fls. 91, o Réu apresentou defesa preliminar, fls. 95/96. A denúncia foi recebida, fls. 97/98, e o Réu, citado, fls. 117. Durante a instrução, foi ouvida a testemunha arrolada pelas

partes, seguindo-se o interrogatório do Acusado (gravação por videoconferência). Em alegações finais o Dr. Promotor de Justiça pediu a condenação do Réu, nos exatos termos da denúncia; por outro lado, a Defensoria Pública insistiu na absolvição. É o relatório. I – FUNDAMENTO. A pretensão é parcialmente procedente. Às fls. 05 foi juntado o Auto de Exibição e Apreensão no qual consta: um pedaço de papelão – embalagem SEDEX e quinze porções de maconha, com peso de 1029,0 gramas. Às fls. 11/12 foram juntadas fotografias. Às fls. 18/20 foi juntado o Laudo Pericial de Exame definitivo n. 229.330/2020 o qual apontou: “Do resultado. Utilizando-se metodologias adequadas para análise do referido material foi detectada a presença da substância Tetrahydrocannabinol (THC), constante na lista F2: Lista de Substâncias Psicotrópicas - Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil da Portaria SVS/MS n. 344/1998 e atualizações posteriores”. Fábio Brocheri Machado, Testemunha, disse que recebeu o pacote destinado ao Réu, conferiu o nome do remetente, era pai do Acusado e contra ele não havia impedimentos no sistema; perguntou para o Réu se conhecia o responsável pelo envio e o endereço, ele disse que sim, então abriu o pacote para conferência e entrega; nesse momento o Acusado se apossou de um pacote de bolacha e a testemunha, para impedi-lo de fugir, segurou-o pelo braço; verificou que, nesse pacote, tinha porções de “maconha”. Deyvid Gonçalves de Oliveira, Réu, ao ser interrogado, disse que, em certa ocasião, utilizava um celular no interior da cela, todavia esse aparelho não lhe pertencia; ao vir a ordem para os presos saírem da cela, desesperou-se e jogou o celular no lixo; o dono do celular exigiu que, como reparação, deveria trazer drogas para o presídio, então passou os dados para essa pessoa, que os utilizou para enviar o pacote para o presídio. Foi coagido. Confrontando-se a prova coligida verifica-se que os entorpecentes foram localizados no pacote de bolachas, em pacote enviado pelo pai do Acusado, cujo destinatário era o próprio Réu. Não é possível que o genitor do Acusado tivesse enviado os entorpecentes sem a ciência deste, e, ademais, a própria conduta do Réu, o qual, antes da conferência, apossou-se do pacote de bolachas onde estavam as drogas demonstra ciência de que lá estavam as porções de “maconha”. A suposta coação não restou demonstrada, trata-se de mera alegação sem qualquer respaldo. A defesa alega que não houve de fato aquisição, pois o pacote não chegou a ser entregue ao Réu, todavia essa tese não merece ser acolhida, na medida em que, com as tratativas e o envio das drogas, ocorreu de fato a aquisição, não se trata de mero ato preparatório. A quantidade dos entorpecentes é elevada, o que poderia demonstrar a finalidade mercantil, todavia o Réu estava preso, portanto o acesso às drogas é difícil, o que justifica a compra de 71,25 gramas de “maconha”. Tratando-se de usuário de entorpecentes, óbvio que as drogas lhe pertenciam, notadamente porque foram por ele adquiridas, todavia, ausentes informações de venda, a conclusão é que os entorpecentes eram destinadas ao uso pelo Acusado. Em síntese, em virtude de todas essas circunstâncias, não se autoriza a prolação de decreto condenatório por infração ao artigo 33 da Lei de Drogas e mister é a desclassificação da conduta imputada ao Réu para a tipificada no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, o que faço com fulcro no artigo 383 do Código de Processo Penal. II – DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade do Acusado, passo à dosimetria da pena. ART. 28, DA LEI 11.343/2006: Atento às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e aos critérios contidos no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 aplico ao Réu a pena de advertência. III – DECIDO. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e o faço para DESCLASSIFICAR a imputação contida na denúncia e o faço para condenar, DEYVID GONÇALVES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, a pena de ADVERTÊNCIA, dando-o como incurso no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06. Dá-se a pena por cumprida. Sem condenação nas custas. O Réu estava em liberdade e, neste momento, ausentes os requisitos da custódia cautelar, poderá interpor eventual recurso nessa condição. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 17 de março de 2022.

Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA